

《【문제1】 다음 질문에 답하시오(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것). (50점)

(물음1) 근로자 A는 甲노동조합을 조직해서 그 설립신고를 하였으나 乙시장은 `설립신고서에서 근로자가 아닌 구직 중에 있는 자의 가입을 허용하고 있다.(`노동조합 및 노동관계조정법」 제2조 제4호 라목)는 사유로 설립신고서를 반려하였다. 이에 甲노동조합은 취소소송을 제기하고자 하는바, 乙시장의 설립신고서 반려는 취소소송의 대상이 될 수 있는가? (25점)》

<문제1의 물음1> 구직자의 노동조합 가입을 이유로 한 설립신고서 반려처분의 취소소송 대상적격 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲노동조합은 설립신고를 하였으나 乙시장은 설립신고서에서 근로자가 아닌 구직 중인 자의 가입을 허용하고 있다는 이유로 설립신고서를 반려하였고, 이에 甲노동조합은 그 반려처분에 대하여 취소소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <乙시장의 노동조합 설립신고서 반려가 취소소송의 대상이 되는 처분에 해당하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙시장의 설립신고서 반려가 취소소송의 대상이 될 수 있는가를 설명한다.

II. 취소소송의 대상

1. 대상적격의 의의

- 취소소송은 행정청의 위법한 처분등을 취소하는 소송으로서, "행정소송법 제19조"에 따라 소송의 대상이 되는 행정작용을 대상적격이라고 한다. "행정소송법 제2조 제1항 제1호"는 처분등을 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용이라고 정의한다.

2. 거부처분의 처분성 인정 요건

- 乙시장의 설립신고서 반려 행위는 신청에 대한 거부 행위이므로, 거부처분으로서의 처분성 인정 여부가 핵심이다. "판례"는 거부 행위가 처분성을 갖기 위한 요건으로 다음과 같은 네 가지를 요구한다.

(1) 공권력의 행사일 것

- 거부 행위가 행정청의 지위에서 행해지는 공법적 행위여야 한다.

(2) 신청에 대한 거부일 것

- 거부의 대상이 되는 신청이 있어야 한다.

(3) 법규상 또는 조리상 신청권이 있을 것

- 거부 행위의 대상이 된 행정작용에 대하여 국민에게 법규상 또는 조리상 신청권이 인정되어야 한다. "판례"는 국민이 행정청에 대하여 신청에 따른 행정행위를 해 줄 것을 요구할 수 있는 법적 지위에 있을 때 신청권이 인정된다고 본다.

① 법규상 신청권

- 관련 법규가 신청인에게 일정한 행정작용을 요청할 수 있는 권리를 부여하고 있는 경우이다.

② 조리상 신청권

- 관련 법규에 명문 규정이 없더라도, 행정작용의 성질상 국민에게 신청을 할 수 있도록 해주는 것이 행정의 합목적성에 부합하거나, 신청권이 없다고 보는 것이 실질적 법치주의에 반하는 경우에 인정된다.

(4) 거부로 인해 신청인의 권리 또는 이익에 영향을 미칠 것

- 신청의 거부로 신청인의 법률상 지위에 직접적인 영향을 미쳐야 한다. 단순히 사실상의 불이익이나 반사적 이익의 침해에 그치는 경우에는 처분성이 부정된다.

III. 사안의 적용

1. 노동조합 설립신고의 법적 성격

- 노동조합 설립신고는 "노동조합법 제10조"에 근거하여 행정청에 제출하는 신고로서, 신고가 수리되면 노동조합으로서 법적 지위를 취득하게 된다. 따라서 설립신고는 단순한 통지행위가 아니라, 신고 수리 여부에 따라 노동조합의 법적 지위가 결정되는 행정행위로 평가된다.

2. 설립신고 반려의 처분성 인정 여부

- 乙시장이 설립신고서를 반려한 행위는 다음과 같은 점에서 처분성을 가진다. ① A 또는 甲노동조합의 권리 행사를 제한한다는 점, ② 법률에 따른 설립신고권을 행사하려는 신청에 대한 거부라는 점, ③ 구체적·직접적 법률상 이익(설립된 노동조합의 법적 지위 확보)을 침해한다는 점, 따라서 설립신고 반려행위는 행정소송법상 취소소송의 대상인 처분으로 볼 수 있다. 다만, 반려 사유가 "노동조합법 제2조 제4호 라목"에 해당하여, 실제로 노조법상 설립요건을 결여한 경우라면, 소송은 행정청의 재량권 행사 적법성 여부를 중심으로 심리될 것이다.

IV. 결론

- 乙시장이 甲노동조합의 설립신고서를 반려한 행위는 노조법에 따른 법규상 신청권에 근거한 신청을 거부한 행위이다. 또한, 그 거부로 인하여 甲노동조합은 노조법상의 법적 지위를 획득하지 못하고 각종 법적 보호를 받지 못하게 되는 구체적이고 직접적인 법률상 불이익을 입는다. 따라서 乙시장의 설립신고서 반려 행위는 "행정소송법 제2조 제1호" 및 "제19조"에서 규정하는 취소소송의 대상이 되는 처분에 해당한다. 甲노동조합은 乙시장의 반려행위가 "노동조합법 제2조 제4호 라목"의 요건을 잘못 해석하거나 판단한 위법한 처분임을 주장하며 취소소송을 제기할 수 있다.